

GEN-A1-ESPECIAL-18

Documento doctrinal estructurado para el temario A1. Fuente normativa local: fuentes_normativas.

GEN - Las formas de actividad administrativa

Artículo 1. Las formas de actividad administrativa

La actividad administrativa puede presentarse doctrinalmente como un conjunto de formas de intervención con distintos objetivos y técnicas. En primer lugar, el marco de actuación general viene dado por la exigencia de que las Administraciones, al desarrollar actividades en el ejercicio de sus competencias, apliquen principios que orientan la intensidad de su intervención. Así, cuando la actuación administrativa limite el ejercicio de derechos individuales o colectivos o imponga el cumplimiento de requisitos para realizar una actividad, deben respetarse exigencias materiales: elección de la medida menos restrictiva, proporcionalidad, motivación de su necesidad para la protección del interés público y justificación de su adecuación para alcanzar los fines perseguidos. Además, se impone una evaluación periódica de los efectos y resultados, lo que conecta la intervención con la constatación posterior de su eficacia. Este enfoque permite comprender la vertiente de “limitación o policía” como intervención orientada a controlar o encauzar conductas para proteger el interés público, especialmente cuando se restringen derechos o se condiciona el desarrollo de actividades. La lógica es que la Administración no puede actuar de manera maximalista: su intervención debe ser la que menos limite y que, al mismo tiempo, resulte idónea para el fin público. Para ejecutar esa finalidad de control, el propio régimen general habilita a las Administraciones a velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación aplicable mediante actuaciones de comprobación, verificación, investigación e inspección. Estas potestades instrumentales se justifican por la necesidad de constatar hechos, actos, elementos o circunstancias relevantes, dentro del ámbito competencial correspondiente y con los límites de la normativa de protección de datos. En segundo lugar, la “actividad de fomento” se vincula a la idea de que el interés general puede justificar apoyos o impulsos a iniciativas que, por sí solas, podrían no desarrollarse en la intensidad deseada. Desde el punto de vista constitucional, la subordinación de toda la riqueza del país al interés general sirve como fundamento material para que la actuación pública incida en la actividad económica, y la iniciativa pública es reconocida como manifestación propia de esa intervención. En este contexto, el fomento puede explicarse como técnica de promoción del desarrollo de actividades o comportamientos alineados con el interés general, diferenciándose del puro control restrictivo porque no se centra tanto en limitar derechos como en impulsar determinadas actuaciones. Finalmente, la vertiente de “servicio público” responde a la lógica de asegurar la prestación de recursos o servicios esenciales cuando así lo permita la intervención del sector público. La Constitución reconoce que, mediante ley, puede reservarse al sector público recursos o servicios esenciales, y prevé también la intervención de empresas cuando lo exija el interés general. Doctrinalmente, esta posibilidad conecta el servicio público con la asunción o garantía pública de prestaciones consideradas esenciales, lo que diferencia esta forma de actividad de la mera regulación o del simple fomento: aquí el elemento nuclear es la conexión con la provisión de servicios o recursos esenciales al servicio del interés general.

Puntos clave:

- La intervención administrativa debe respetar proporcionalidad, medida menos restrictiva, motivación y adecuación al interés público cuando limite derechos o exija requisitos.
- La Administración debe evaluar periódicamente los efectos y resultados de sus medidas, conectando control e impacto.
- Para verificar el cumplimiento de requisitos puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar hechos y circunstancias relevantes, con límites por protección de datos.
- La subordinación de la riqueza al interés general y la iniciativa pública en la actividad económica son fundamentos constitucionales del papel interventor del sector público.
- El fomento se explica como impulso o promoción alineada con el interés general, diferenciándose de la mera restricción de derechos.
- La reserva legal al sector público de recursos o servicios esenciales y la intervención de empresas responden a la lógica propia de la actividad orientada a asegurar prestaciones esenciales.

- La clasificación limitación/policía, fomento y servicio público se entiende doctrinalmente como tres formas de orientar la actividad: control restrictivo, apoyo/incentivo e introducción/garantía de prestaciones esenciales.
- Las formas de intervención dependen del fin perseguido y de la técnica empleada (restricción, verificación o impulso/garantía).

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 4] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 128] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 128 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 2. Actividad de limitación o policía

La actividad administrativa de limitación o policía se entiende doctrinalmente como el conjunto de medidas mediante las cuales la Administración, en el ejercicio de sus competencias, restringe el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exige requisitos para el desarrollo de una actividad. Su finalidad inmediata es permitir que esa actividad se someta a condiciones que protejan el interés público, evitando que el ejercicio de libertades o la realización de actividades produzcan riesgos, disfunciones o efectos contrarios al orden público o a los bienes colectivos cuya tutela corresponde a la Administración. El rasgo central de esta actividad es su carácter intrusivo: no se limita a informar o facilitar, sino que impone límites o exigencias. Precisamente por esa incidencia sobre derechos o sobre la libertad de actuación, la doctrina exige que la intervención responda a un juicio de proporcionalidad. Ello implica, en primer lugar, que la medida sea adecuada para lograr el fin perseguido (protección del interés público) y, en segundo lugar, que no exista una alternativa menos restrictiva igual de eficaz. La Administración debe, por tanto, “elegir la medida menos restrictiva”, lo que obliga a comparar opciones y a justificar por qué la escogida es la menos lesiva. Además, la intervención debe ir acompañada de una motivación suficiente de su necesidad para la protección del interés público, y de una justificación de su adecuación a los fines. En términos prácticos de oposición, esto se traduce en que no basta con afirmar la existencia de un interés público, sino que hay que explicar el vínculo entre ese interés y la medida adoptada, así como por qué la limitación concreta resulta idónea. La actividad de limitación o policía también está sujeta a la exigencia de evaluación: la Administración debe evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos, de manera que pueda confirmarse que la intervención produce el impacto esperado y, si no, ajustar su actuación. Esta evaluación

conecta con el control de la proporcionalidad a lo largo del tiempo. Por último, la doctrina distingue que el cumplimiento de los requisitos puede exigir actuaciones de control material. La Administración puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias necesarias, siempre dentro de sus competencias. Estas facultades de comprobación no son ilimitadas: deben respetar los límites legales aplicables, en particular los que derivan de la protección de datos de carácter personal, lo que condiciona el modo y alcance del control. En suma, la limitación o policía se caracteriza por imponer requisitos o restricciones para proteger el interés público, pero sometida a un estándar reforzado: proporcionalidad (y elección de la medida menos restrictiva), motivación de la necesidad y adecuación, evaluación periódica de resultados y ejercicio de facultades de comprobación dentro de los límites —incluidos los de protección de datos— establecidos por la normativa aplicable.

Puntos clave:

- La actividad de limitación o policía restringe derechos o exige requisitos para desarrollar actividades, en el marco de las competencias administrativas.
- Su finalidad doctrinal es proteger el interés público mediante medidas que incidan en la esfera de los particulares.
- Debe aplicarse el principio de proporcionalidad y elegirse la medida menos restrictiva posible.
- La Administración ha de motivar la necesidad de la intervención y justificar su adecuación para alcanzar los fines perseguidos.
- La intervención requiere evaluación periódica de efectos y resultados para verificar su efectividad.
- Para controlar requisitos, la Administración puede comprobar, verificar, investigar e inspeccionar hechos y circunstancias necesarias.
- Las facultades de control están limitadas por la legislación aplicable, especialmente por las reglas de protección de datos personales.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público — Artículo 4] Fuente: BOE-A-2015-10566 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>

Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

Artículo 3. Actividad de fomento

La actividad de fomento se caracteriza, en términos doctrinales, por la acción de una Administración pública dirigida a promover la realización de determinadas finalidades de interés general o de utilidad pública. No se trata

de una actuación meramente reglada o de ejecución directa de una función pública, sino de una intervención que impulsa comportamientos, proyectos o actividades en el ámbito de sujetos que no son la propia Administración. En este marco, la subvención aparece como una de las manifestaciones típicas del fomento: permite canalizar recursos económicos hacia destinatarios externos con la finalidad de incentivar la consecución de objetivos considerados públicos. Desde la perspectiva del concepto legal de subvención, el rasgo nuclear es que la Administración realiza una disposición dineraria a favor de personas públicas o privadas, sin que exista una contraprestación directa del beneficiario. Este elemento de “ausencia de equivalencia inmediata” diferencia la subvención de los pagos vinculados a un intercambio contractual o a la obtención directa de un servicio por parte del beneficiario. En segundo lugar, la disposición dineraria debe estar sujeta al cumplimiento de un fin determinado. La ley contempla que el destino de los fondos puede consistir en el desarrollo de un proyecto, la ejecución de una actividad, la adopción de un comportamiento singular o la atención de una situación que se financia; en todos los casos, el beneficiario debe asumir obligaciones materiales y formales. Por tanto, el fomento mediante subvención se articula como un instrumento condicionado: el apoyo económico no es puramente discrecional en su aplicación, sino que queda ligado a objetivos y cargas exigibles al beneficiario. En tercer lugar, el objeto de la financiación debe conectarse con el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o con la promoción de una finalidad pública. Esta finalidad opera como criterio de orientación teleológica: la subvención no se dirige a cualquier transferencia de recursos, sino a aquellas que buscan impulsar resultados con proyección social o pública. La delimitación doctrinal exige atender también a los límites del ámbito de la ley. En particular, no se consideran subvenciones determinadas aportaciones dinerarias entre Administraciones cuando se destinan a financiar globalmente la actividad o actuaciones concretas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. Asimismo, se excluyen aportaciones dinerarias entre agentes de una Administración cuando sus presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenecen, y también ciertas cuotas satisfechas por entidades que integran la Administración local a asociaciones previstas en una norma específica. Además, el concepto excluye supuestos prestacionales del sistema de Seguridad Social y otras prestaciones y beneficios expresamente contemplados, de modo que no toda ayuda económica encaja como subvención. En conclusión, la subvención como modalidad de fomento se entiende como una disposición dineraria condicionada, sin contraprestación directa, orientada al cumplimiento de objetivos vinculados al fomento de finalidades de utilidad pública o interés social, respetando los ámbitos excluidos que impiden su calificación como subvención en determinados supuestos.

Puntos clave:

- La actividad de fomento busca impulsar finalidades de utilidad pública o interés social mediante actuaciones sobre terceros.
- La subvención es una manifestación característica del fomento: transfiere dinero para promover objetivos públicos.
- Elemento esencial: la disposición dineraria se realiza sin contraprestación directa del beneficiario.
- Debe haber un destino condicionado: proyecto, actividad, comportamiento o situación financiada, con obligaciones materiales y formales.
- La finalidad financiada debe encajar en el fomento de utilidad pública o interés social o la promoción de una finalidad pública.
- No toda entrega de dinero es subvención: hay exclusiones legales del ámbito de aplicación.
- Entre Administraciones puede no considerarse subvención si responde a financiación global o actuaciones concretas sin convocatoria pública.
- Se excluyen determinadas aportaciones de cuotas de entidades de la Administración local a asociaciones previstas en el marco indicado.
- El concepto excluye prestaciones del sistema de Seguridad Social y otras ayudas/beneficios expresamente determinados.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones — Artículo 2] Fuente: BOE-A-2003-20977 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977>

Artículo 2. Concepto de subvención. 1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública. 3. Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. c) También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. e) Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. h) El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito. i) Las ayudas económicas a

las víctimas de violencia de género concedidas según lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a las víctimas de violencias sexuales concedidas según lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Artículo 4. El servicio público: concepto y clases

El “servicio público” se entiende doctrinalmente como una forma de actuación de las Administraciones orientada a satisfacer necesidades de interés general mediante la organización y prestación de una actividad a los destinatarios. Su punto de conexión con el interés general aparece en el plano constitucional al subordinar toda la riqueza del país al interés general y al reconocer la iniciativa pública en la actividad económica, con posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales y de acordar la intervención de empresas cuando lo exija ese interés general. Desde esta perspectiva, el servicio público no es un concepto puramente económico, sino una técnica de prestación que se justifica por la finalidad pública. En el ámbito local, el artículo 85 LRBRL establece expresamente qué debe considerarse “servicio público local” y cómo debe gestionarse cuando se trate de servicios de competencia local. Según dicha regla, son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. La noción doctrinal clave es, por tanto, la vinculación entre servicio público y competencia: el servicio se califica como “local” porque lo presta la entidad local, pero además porque opera dentro del ámbito competencial que le corresponde. La doctrina también destaca que la gestión del servicio público local ha de responder a criterios de sostenibilidad y eficiencia. El propio artículo 85 articula un catálogo de modalidades de gestión. En el plano de la gestión directa, se contemplan distintas fórmulas que implican que la propia entidad local asuma la prestación (gestión por la propia entidad) o la realice a través de entidades instrumentales locales (organismo autónomo local o entidad pública empresarial local). Asimismo, se prevé la posibilidad de utilizar una sociedad mercantil local de capital íntegramente público, pero condicionada: su utilización frente a las fórmulas anteriores exige acreditar mediante una memoria justificativa que resulta más sostenible y eficiente, atendiendo a criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Esta exigencia se acompaña de un soporte procedimental adicional: la memoria y el asesoramiento recibido han de constar en el expediente, elevarse al Pleno para su aprobación e incluir informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico, que deben publicitarse, con informe del interventor local que valore la sostenibilidad financiera. En cuanto a la gestión indirecta, el artículo 85 remite a las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la normativa de contratos del sector público, manteniendo como eje doctrinal la necesidad de encajar la modalidad elegida con el régimen aplicable en materia contractual. Por último, es relevante distinguir el servicio público del ámbito típico de otras técnicas de actuación pública, como la limitación (facultades restrictivas) o el fomento (medidas de apoyo). En particular, la subvención opera como una manifestación característica del fomento, y ello ayuda a comprender que el servicio público responde a la lógica de la prestación organizada por la Administración, no a la lógica de la ayuda o estímulo a terceros, aunque puedan coexistir en la satisfacción de finalidades de interés general.

Puntos clave:

- El servicio público se justifica por la finalidad de interés general y se relaciona con la iniciativa pública en actividad económica.
- En el plano local, son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales dentro de sus competencias.
- Para servicios de competencia local, la gestión debe orientarse a la máxima sostenibilidad y eficiencia.
- La gestión directa incluye fórmulas como gestión por la propia entidad y entidades instrumentales locales.
- La utilización de sociedad mercantil local de capital público exige una memoria justificativa que acredite sostenibilidad y eficiencia frente a otras opciones.
- La memoria justificativa y los informes de coste deben constar en el expediente y elevarse al Pleno; además, se prevé publicitar ciertos extremos.

- El interventor local emite informe valorando la sostenibilidad financiera en el marco procedimental descrito.
- La gestión indirecta se encauza mediante las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos, según la remisión del artículo.
- La subvención es una manifestación característica del fomento, lo que ayuda a distinguirlo de la lógica propia del servicio público.
- El esquema del artículo 85 LRBRL queda delimitado al servicio público local, sin convertir automáticamente sus modalidades en reglas universales para todas las Administraciones.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local — Artículo 85] Fuente: BOE-A-1985-5392 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392>

Artículo 85. 1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. 2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local. b) Organismo autónomo local. c) Entidad pública empresarial local. d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 128] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 128 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 5. Formas de gestión de los servicios públicos

El epígrafe “Formas de gestión de los servicios públicos” se centra en cómo deben prestarse los servicios públicos en el ámbito local, vinculándolo a las competencias de las entidades locales. En este marco, el punto de partida es que son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales dentro del ámbito competencial que les

corresponde. A partir de ahí, la norma impone una regla de elección: los servicios públicos de competencia local deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, pero el criterio no opera como una libertad absoluta, sino dentro de un elenco de modalidades legalmente previstas. La estructura doctrinal del precepto distingue, de un lado, la gestión directa y, de otro, la gestión indirecta. En la gestión directa, la prestación se realiza a través de medios de la propia entidad local o de entes instrumentales locales vinculados a ella. El artículo concreta varias posibilidades: (i) gestión por la propia entidad local; (ii) organismo autónomo local; (iii) entidad pública empresarial local; y (iv) sociedad mercantil local de capital público. Ahora bien, el uso de las formas consistentes en entidad pública empresarial local y sociedad mercantil local aparece sometido a cautelas adicionales: solo puede acudir a las letras c) y d) cuando se justifique en una memoria que resultan más sostenibles y eficientes que las modalidades de letras a) y b). Esa justificación no es meramente retórica, sino que exige atender a criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión, y acompañar una memoria justificativa que se incorpore al expediente. Además, el precepto determina un procedimiento reforzado cuando se opta por esas modalidades. La memoria justificativa debe incluir también el asesoramiento recibido, y se eleva al Pleno para su aprobación. En esa misma lógica de transparencia, se exige que figuren en el expediente informes sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido, y que tales elementos sean publicitados. Finalmente, interviene el interventor local mediante un informe que valora la sostenibilidad financiera de las propuestas. Con ello, la gestión directa no se limita a describir “quién” presta el servicio, sino que incorpora una evaluación económica-financiera y un control institucional. Por lo que respecta a la gestión indirecta, el artículo la configura como aquella que se realiza mediante distintas formas previstas para el “contrato de gestión de servicios públicos” en el texto de contratos del sector público. Es decir, la gestión indirecta se articula a través de instrumentos contractuales, manteniendo la idea de que la elección debe responder a sostenibilidad y eficiencia, pero remitiendo a las modalidades contractuales previstas en la legislación de contratación. Asimismo, el precepto añade una consideración sobre el ámbito del personal y el ejercicio de funciones reservadas: la forma de gestión que se adopte debe tener en cuenta lo dispuesto en el estatuto básico del empleado público, en lo relativo a funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos. De este modo, la gestión, directa o indirecta, queda condicionada también por el reparto de competencias en materia de función pública dentro del servicio.

Puntos clave:

- Los servicios públicos locales son los que prestan las entidades locales dentro de sus competencias.
- Los servicios de competencia local deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente entre las modalidades del artículo.
- La gestión directa incluye: propia entidad local, organismo autónomo local y entidad pública empresarial local, y sociedad mercantil local de capital público.
- Para usar entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local se exige memoria justificativa sobre sostenibilidad y eficiencia frente a las modalidades de letras a) y b).
- La memoria justificativa debe valorar rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
- En el expediente deben constar informes sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido, que deben publicitarse.
- La memoria justificativa del asesoramiento recibido se eleva al Pleno para su aprobación.
- El interventor local debe informar valorando la sostenibilidad financiera de las propuestas.
- La gestión indirecta se articula mediante las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la normativa de contratos del sector público.
- Al elegir la forma de gestión debe respetarse el régimen del estatuto básico del empleado público sobre funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local — Artículo 85] Fuente: BOE-A-1985-5392 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392>

Artículo 85. 1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. 2. Los servicios públicos de

competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local. b) Organismo autónomo local. c) Entidad pública empresarial local. d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.

Artículo 6. Gestión indirecta mediante concesión de servicios

La gestión indirecta mediante concesión de servicios se configura, en el ámbito del artículo 284 de la LCSP, como una forma en que la Administración gestiona servicios de su titularidad o competencia sin realizarlos directamente. La nota definitoria es que esa gestión se articula mediante un contrato de concesión de servicios y se refiere, por tanto, a servicios que sean "susceptibles de explotación económica por particulares". Esto conecta la concesión con la posibilidad real de que el servicio pueda explotarse en el tráfico económico por un tercero, lo que exige que el objeto contractual sea encajable en ese marco de explotación. Ahora bien, el artículo establece límites expresos para preservar el ámbito propio de la Administración. En primer lugar, no pueden prestarse mediante concesión de servicios aquellos servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Doctrinalmente, esto opera como un criterio material: aunque el servicio sea gestionable indirectamente por razón de su explotación económica, quedará excluido si conlleva potestades o autoridad propias del poder público. La concesión, por tanto, no es un instrumento para privatizar funciones que comporten autoridad, sino para gestionar servicios en términos compatibles con la prohibición legal. Además, cuando la concesión se refiera a "servicios públicos", el artículo 284 impone una exigencia previa de ordenación normativa del servicio. Antes de contratar, debe haberse establecido su régimen jurídico con tres contenidos mínimos: (i) una declaración expresa de que la actividad se asume por la Administración respectiva como propia; (ii) la determinación del alcance de las prestaciones en favor de los administrados; y (iii) la regulación de los aspectos jurídicos, económicos y administrativos relativos a la prestación. Esta regla es relevante para oposición porque muestra que la concesión no sustituye la necesidad de definir previamente el marco del servicio cuando se trata de servicio público. En cuanto al contenido del contrato, el artículo exige claridad en el "ámbito de la concesión", tanto en el plano funcional como territorial. Es decir, el contrato debe delimitar con precisión qué funciones o facetas del servicio se conceden y en qué territorio se desarrollará la prestación. La finalidad doctrinal de esta exigencia es evitar indeterminaciones: el ámbito debe quedar ordenado, en términos de prestaciones y localización, de manera comprensible. En suma, la concesión de servicios opera como gestión indirecta contractual de servicios de titularidad o competencia administrativa, condicionada a la explotabilidad económica por particulares, excluida para supuestos con ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos y, en caso de servicios públicos,

precedida de un régimen jurídico del servicio; además, el contrato debe concretar funcional y territorialmente su ámbito.

Puntos clave:

- La concesión de servicios es una forma de gestión indirecta mediante contrato para servicios de titularidad o competencia de la Administración.
- Solo procede si el servicio es susceptible de explotación económica por particulares.
- Quedan excluidos los servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos.
- Si se trata de servicios públicos, antes de contratar debe existir un régimen jurídico previo del servicio.
- El régimen jurídico previo debe declarar la asunción de la actividad como propia, fijar el alcance de prestaciones y regular aspectos jurídicos, económicos y administrativos.
- El contrato debe expresar con claridad el ámbito de la concesión en el orden funcional y en el territorial.
- La delimitación del ámbito es un requisito de precisión contractual: qué se concede y dónde.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público — Artículo 284] Fuente: BOE-A-2017-12902 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>

Artículo 284. Ámbito del contrato de concesión de servicios. 1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 2. Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. 3. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.